

1500590-72.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500590-72.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500590-72.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079342/2022 - 03º D.P.

DIADEMA, 2079342 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Henrique Cavalcanti

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI, qualificado às fls. 11/12, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º- A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22 de março de 2022, por volta das 18h00, na Rua Jovercina Paula de Oliveira, altura do nº 210, bairro Conceição, nesta cidade e comarca de Diadema, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Eliege Ferreira de Miranda Pereira e Berenice Mota de Oliveira Silva, subtraiu, para ele, o veículo automotor JEEP/Renegade, de placas FPE-7457.

Preso em flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 29/31). A denúncia foi recebida em 08/04/2022 (fl. 76). Citado (fl. 151), constitui advogado particular, sendo apresentada sua defesa inicial às fls. 117/133, com indeferimento dos pedidos de revogação da preventiva (fls. 163/164) e denegação da ordem de HC (fls. 157/162).

Em audiência una foram ouvidas a vítima Eliege, duas testemunhas comuns, uma

testemunha de defesa, homologada a desistência das Partes quanto à oitiva da vítima Berenice que está grávida e sem condições emocionais de participar da audiência, e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o aumento pelo emprego de arma de fogo, a ser cumprida em regime fechado, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem do recurso em liberdade.

A d. Advogada, ao lhe ser passada a palavra para debates orais, requereu prazo para juntada de memoriais, o que foi indeferido diante da intempestividade do pedido e discordância ministerial, quem não teve essa oportunidade por já ter se manifestado em debates orais. Então nestes, houve a arguição pela Defesa, de nulidade do reconhecimento do réu feito sozinho. E no mérito, pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória, ou a desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, em regime mais brando, e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Afasto alegação de nulidade dado que o réu foi colocado na presença de mais dois presos para reconhecimento em solo judicial, como se vê do video. E improcede alegação de ilegalidade do reconhecimento realizado em sede policial (fl.14), em razão da segurança do reconhecimento feito pela vítima Eliege nas duas fases, além de salientar que o artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações a serem seguidas, e não exigência. Nestes termos: "Audiência realizada por videoconferência, justificada a medida nos termos do artigo 185, § 2º, do CPP e em razão da atual situação de pandemia. Prejuízo não demonstrado. Acusado reconhecido pela vítima nas duas fases da persecução de forma segura. Inteligência do artigo 226 do Código de Processo Penal. Dispositivo que traz mera recomendação no sentido de ser o réu colocado ao lado de outras pessoas quando da realização do ato, algo diverso de obrigatoriedade. Tese da Defesa há muito desgastada, a par de contrária à pacífica jurisprudência. Precedentes."(Apelação Criminal nº 1501951-98.2020.8.26.0536, São Vicente, rel. Farto Salles, j. 03/02/2022).

No mérito, a ação procede. Vejamos.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 14, auto de exibição, apreensão, entrega do veículo (fl. 17/18) localizado em poder do meliante. Ressalto que: "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório." (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas BMJ 91/6 e RDJ 18/66). A autoria é inconteste.

A vítima Eliege Ferreira de Miranda Pereira, ouvida extrajudicialmente (fl. 10), informou que é proprietária do veículo Renegade de cor cinza – placas FPE- 7457 e estava com sua colega de trabalho quando ao entrar no veículo, na posição de motorista, foi abordada por um indivíduo que portava uma arma de fogo e mediante ameaça, exigiu a entrega do veículo, o que foi atendido. Após, o indivíduo ingressou no veículo e tomou rumo ignorado, oportunidade que avisou seu filho e acionou a polícia militar. Reconheceu o indivíduo que a abordou.

Em juízo perante ao Juiz imparcial, a vítima Eliege alegou que saída da escola, por volta das 17:50 horas, para pegar seu carro deixado na rua. Entrou no carro com a Berenice e o rapaz bateu com a arma no para brisa do carro e mandou elas descerem. Viu a ponta da arma e era uma arma de fogo, pois viu o cano batendo no vidro. Ele mandou elas não gritarem e pôs a mão na boca para ficarem quietas. Foi tirar o cinto de segurança, ele entrou no banco do motorista. Pediu para pegar a bolsa com as provas das crianças da escola que estavam na mochila e seu celular. Ele deixou ela pegar e levou só o carro. Ele não sabia ligar o carro e disse para ele apertar o botão. Pegou a bolsa e ele acelerou e foi embora. Voltou para a escola, ligou para 190 e para seu filho e ele acionou amigos motoboys, e um deles disse para irem para um certo local, Estrada do Alvarenga, e perto do Cemitério seu filho viu o

carro e com ajuda de amigos de moto, acuraram ele numa rua sem saída e os meninos pularam em cima dele e o seguraram até a chegada da viatura policial. Foi para o DP. O assaltante estava de máscara, capuz do moletom, e não deu para ter certeza se o réu lhe roubou, mas ele vestia a mesma roupa e pela altura dele, mais alto que ela, e bem garotão, na faixa de uns vinte e poucos anos. Entre o momento do roubo e a localização do réu, deu aproximadamente uma hora, tendo reconhecido o réu por volta das 20:00 horas do dia do crime. Reconhece o réu como sendo o que está com o número 1. Sua amiga Berenice não teve muito contato com o réu, que ficou do seu lado do carro. O roubo foi praticado por um único indivíduo, que estava a pé, tanto que Berenice já tinha avisado que vinha vindo alguém na direção delas, mas achou que pudesse ser algum aluno. Reconheceu o réu pela parte do rosto, pela roupa que ele vestia, cor da pele. A ligação feita por seu filho foi pelo whatsapp e ele só avisou que tinham achado o carro e que era para ela ir ao DP. A ligação estava horrível e não disse ao seu filho que não seria aquela pessoa, e estava muito escuro e péssima a ligação. Não foi orientada a reconhecer o réu, nem no DP e nem nessa audiência. Foi tudo muito cansativo e estressante para si o tempo que ficou no DP, sentindo que não estava sendo tratada como vítima. Não viu o réu agredido, ele não estava com o rosto machucado. Acredita que o réu usou uma arma de fogo contra si, e na covardia, contra uma mulher, e ele pôs a arma para fora e bateu com o cano no vidro, obedeceu, porque viu que ele estava armado, e ainda esbarrou nele e sentiu a arma na cintura dele. Não tem interesse em prejudicar ninguém e quer fechar esse ciclo e não quer que outras pessoas sejam roubadas, menos ainda na frente de uma escola, com crianças, que poderiam ter sido atropeladas, porque o réu saiu em alta velocidade.

A vítima Berenice Mota de Oliveira Silva, ouvida apenas em solo policial (fl. 09), pois está grávida e não quis depor em juízo por estar se sentindo mal, à época declarou que estava de carona com sua amiga e vítima Eliege quando foram abordadas por um indivíduo que aparentava estar armado, o qual exigiu a entrega do veículo, o que foi atendido pela motorista, descendo do veículo após as ameaças. Após, o indivíduo ingressou no veículo e tomou rumo ignorado, informando que não tinha condições de reconhecer o indivíduo que realizou a abordagem.

A testemunha Pedro Henrique de Miranda Pereira, ouvido em solo policial (fl. 08), declarou que foi comunicado por sua mãe que ela havia acabado de ser assaltada, sendo subtraído o veículo Renegade, e como é motociclista, de imediato passou a tentar localizar o veículo nas proximidades, até que em determinado momento logrou êxito em localizar o veículo sendo conduzido por um indivíduo, passando a sinalizar para o condutor parar, tendo acionado a polícia militar.

Sob o crivo do contraditório, essa testemunha disse que estava trabalhando na rua, como motoboy de entregas. Sua mãe saiu da escola por volta das 18:05. Ela lhe telefonou, nervosa, e a amiga dela Berenice que estava menos nervosa contou do roubo do carro. Como trabalha com moto, pediu ajuda a colegas motoboys e foram fazer uma ronda na tentativa de localizar o carro. Um amigo seu falou para irem na direção do Eldorado. No caminho do Alvarenga, viu o carro com o réu dirigindo. Ele viu as motos vindo com farol alto para ele parar, ele acelerou mais e entrou numa rua sem saída e desceu do carro para cima deles, e o seguraram e chamaram a polícia, que chegou e o levaram ao DP. O réu lhe disse que estava no BO e que estava ganhando para roubar o carro e levar para outro lugar. Conseguiu localizar ele cerca de uma hora depois do roubo, mas sem arma, que provavelmente ele a dispensou. Sua mãe teve certeza que foi o réu quem a roubou e que ele bateu com o cano da arma no vidro, e ele estava com a mesma blusa. Ligou para sua mãe para avisá-la que tinham achado o carro, mas não mostrou o réu pelo vídeo, nem sua mãe ficou falando que não era ele, porque não mostrou ele. Ela só teve contato com ele no DP. Não houve agressão contra o acusado, mas na hora que o réu saiu do carro, sua moto caiu e ele veio para cima de si, e resistiu, e então empurrou ele, que ele caiu e foi imobilizado ali. Foi procurar o réu acompanhado de outros amigos motoboys. Não pediu para sua mãe reconhecer o réu. O réu disse que estava roubando o carro e ganhando para isso. Localizou o réu sozinho no carro e foi quem sua mãe reconheceu e não sabe se ele roubou sozinho, porque não presenciou os fatos. Reconheceu o réu nessa audiência como sendo a pessoa que conduzia o carro da sua

mãe.

A testemunha Roger Lucchini de Oliveira, ouvido em sede policial (fl. 06), relatou que foi irradiado via Copom o roubo de um veículo (Renegade cor cinza - placas FPE-7457) e logo em seguida, em deslocamento, identificaram o veículo na via sendo ocupado por um indivíduo LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE o qual tinha sido detido pela testemunha Pedro Henrique de Miranda Pereira (filho da vítima Eliege). Os policiais então realizaram a abordagem e não foi encontrando nada de ilícito além do próprio veículo subtraído.

Em juízo esse policial reiterou que via Copom foi pago que um indivíduo foi detido por populares que o haviam detido como possível autor do roubo do veículo. Conteve os populares e conduziu a testemunha e o suspeito ao DP. Questionado, o réu disse que só tinha ido levar o carro para um terceiro. Não lembra do réu, porque era noite, e viu pessoas cercando o réu tentando segura-lo e ele tentando fugir e cada um segurava ele, não tendo visto ele ser agredido, e só o algemou porque ele queria se defender das pessoas que o acusavam, e para sua segurança, o levou ao DP algemado. Primeiro chegou uma informação, e ao chegar no local onde o indivíduo estava detido obteve a informação de que ele tentava se evadir e umas três pessoas o seguravam e outras só ficaram olhando, e não presenciou o réu sendo agredido por ninguém. Não sabe se o réu agiu sozinho.

A testemunha de defesa Anailson Nascimento Mendes, em juízo declarou que não presenciou os fatos. O réu estava consigo das 15:40 até às 20:00 horas, conversando em sua casa, e saiu para ir para a casa da mãe dele. Ficou surpreso com a prisão dele. O réu estava fazendo bico e entregando Curriculum. Os pais dele ajudam ele bastante.

O indiciado Luiz Henrique, em solo policial (fls. 11/12), quedou-se silente.

Sob o crivo do contraditório, o réu disse que dois rapazes iam lhe pagar um dinheiro para levar o carro até outro local e assim teria dinheiro para pagar a pensão que estava atrasada. No dia estava nervoso e machucado por ter levado uma surra. O filho da vítima ligou para a mãe dele e lhe mostrou e a mãe dele disse que não foi ele quem a roubou. E foi ele quem lhe deu um soco na boca e depois os amigos dele lhe agrediram. Já foi processado por briga com a mãe de seu filho. Estava na casa de sua mãe quando seu amigo pediu ajuda para limpar a casa dele e ficou até por volta das 17:00 horas, onde fizeram comida, jantaram, assistiram filme, e por volta das 20:00 horas recebeu a ligação de que era para ele ir pegar o carro na Estrada de Baixo, próximo de onde mora, e no meio do caminho, na Estrada do Rufino, perto da rua Xico Mendes, e lhe deram uma carona até onde o carro estava parado, e lhe entregaram a chave. Ia deixar o carro estacionado com a chave no quebra sol, perto do Cemitério, e então ficaria nas proximidades para receber o dinheiro, e ia voltar para sua casa a pé, para a Estrada da Encosta. Tem habilitação. Um conhecido seu que conhece outras pessoas falou sobre ganhar um dinheiro fácil, e logo depois lhe telefonaram quando estava jantando e assistindo filme na casa de seu amigo, porque não deixaram nada agendado. O filho da vítima e mais dois amigos dele lhe agrediram, e foi ao hospital sendo advertido de que não deveria dizer que tinha sido agredido, tomando só um remédio, sendo dispensado, não tendo passado por nenhuma perícia.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, especialmente pelas declarações das vítimas e pelo reconhecimento pessoal positivo feito por Eliege, tanto em solo policial como em juízo, bem como pelo relato do filho dela, quem primeiro localizou o réu em poder do veículo recém subtraído de sua mãe, tudo em conformidade com os depoimentos do policial que abordou o réu na posse da "res", sem prova contrária ou favorável ao acusado, quem embora negue os fatos tentando fazer crer que apenas receiptasse o veículo, não fez prova disso.

Ora, o contexto probatório, como visto, não favorece o acusado, de modo que a procedência do pedido condenatório pelo crime de roubo majorado consumado, é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, nem indício de que a vítima ou a testemunha Pedro tenham interesse em prejudicar o réu, pois como aquela falou, quer apenas que seja feita

justiça, já que era o réu quem estava em poder de seu carro, antes por ele roubado, e não quer que isso aconteça com outras pessoas.

Ressalto que as declarações da vítima Eliege, proprietária do veículo, foram harmônicos e concisos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o modus operandi do acusado, a forma em que foi abordada, mediante a grave ameaça sofrida através do uso de uma arma de fogo apontada para si, motorista, subjugando-a e reduzindo qualquer esfera de defesa de seu patrimônio. Tanto que ela reconheceu o acusado, que foi localizado em poder da res, minutos depois, sem provar a posse lícita, nem a mera receptação do bem, não convencendo sua versão de que estava na companhia de um amigo e recebeu uma ligação de pessoas que sequer conhecia, para ir buscar um carro num determinado local, tendo pego carona no caminho, sem explicar como tudo isso teria sido possível, e ter sido abordado no local onde ia deixar o carro, quando na verdade ele só foi parar na rua sem saída porque perseguido pelos motoqueiros que pediam para ele parar, e acelerou para fugir deles, não conseguindo por ter entrado na rua sem saída.

Veja, se fosse verdadeira a versão judicial do réu de que receberia trezentos reais pela condução do carro roubado ao local indicado, o normal e correto seria ele já ter dito isso a autoridade policial, quando ele optou pelo silêncio, conduta que não se amolda a um inocente com testemunha a provar seu álibi, inclusive. E sobre esse, aponto que a testemunha de defesa trouxe contradições com a versão do réu no sentido de onde estavam e o que estariam fazendo juntos no momento do crime, já que aquele apontou que estavam em sua casa conversando, enquanto o réu alegou que estava limpando a casa de amigo e depois fizeram compras, cozinham, jantaram e assistiam um filme, sendo que nada disso foi dito por Anailson, amigo do réu, pelo que desconsidero tal versão, até pela nota fiscal juntada pela defesa que por volta das 16 horas se deu a tal compra, dado que o acusado disse que só as 17:00 horas teriam acabado de limpar a casa e então ido fazer as compras, mais um indicativo de que mente.

Anoto, ainda, que a declaração da vítima deve ser prestigiada pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, a palavra da ofendida revelou-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios. Veja: em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir. (TJSP - Apelação Criminal nº 1500517-62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j.

18.08.2021). Portanto, afastada tese defensiva de que a vítima não tenha reconhecido o réu, pois ela disse que o reconheceu pela altura, cor da pele, idade, roupas e parte de seu rosto. E negou tenha dito a seu filho que não seria ele, pois não o viu por vídeo via whatsapp em nenhuma ligação, até porque a ligação feita pelo seu filho estava muito ruim, e foi só de áudio.

Some-se a isso o depoimento do policial militar também se revelou coeso e harmônico em ambas as fases da persecução criminal, pois bem demonstrado, após ser comunicado do roubo, se desdobrando em sua diligência e no encontro da res em posse do acusado, após a abordagem do filho da vítima que encontrou o veículo. Não houve em nenhum momento uma justificativa do réu sobre a posse do veículo encontrado. Ora, seria o momento oportuno para que o acusado demonstrasse ao agente de segurança estar fazendo apenas o transporte do veículo pelo valor de R\$ 300,00, mas optou pelo silêncio em solo policial, e não provou sua negativa de autoria em solo judicial, pois como já dito, sua testemunha de defesa entrou em contradição consigo, e por isso desconsiderada sua versão.

O policial militar, assim como a testemunha Pedro e a vítima Eliege sequer conheciam o meliante, razão pela qual seus depoimentos tem valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente. Neste sentido: Aliás, não há razão para se desprezar a palavra dos policiais que dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são

detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão só e exclusivamente por serem policiais. (RJDTACRIM 42/215)

No tocante à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a prova oral colhida em Juízo é suficiente para demonstrar que a ameaça foi exercida com emprego do armamento, como sempre afirmado por Eliege, e embora Berenice não tenha visto a arma, porque estava do outro lado do veículo, ela afirmou que ele parecia estar armado. E ainda o objeto não tenha sido apreendido nem periciado, é de rigor acolher a majorante diante do contexto probatório já analisado acima, que não deixa dúvida acerca do seu emprego a gerar mais intimidação e aniquilar chance de defesa das vítimas, contribuindo para o êxito da empreitada criminosa, de forma mais rápida. Tanto que a Sra. Eliege teve certeza que o réu estava armado e viu efetivamente o cano da arma sendo por ele batido no vidro, e por isso não reagiu, de modo que o emprego do armamento colaborou para a pronta consumação do crime e seu êxito, de modo que deve ser considerado a aumentar a pena. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do E. STF:

"HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA. PRESCINDÍVEL APREENSÃO DA ARMA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO. 1. A qualificadora de uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância. 2. Ordem denegada." (STF - HC 92.451/SP - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 09.09.2008 - DJU 06.02.2009 - grifei);

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra 'in re ipsa'. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (STF - HC 96.099/RS - 1ª T. (TRIBUNAL PLENO) - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 04.11.2008 - DJU 05.06.2009 - grifei)

Nesses termos, fica rejeitado o pedido de afastamento da causa de aumento de pena. Dito isso, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado na denúncia.

O arcabouço fático-probatório amealhado é capaz de afirmar de maneira inequívoca a responsabilidade criminal do réu, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória, nem há de se falar em desclassificação para o crime de receptação. Portanto, de rigor sua condenação.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal que não reputo negativas, fixo em primeira fase a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira dos condenados.

Em segunda fase, ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

Em terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, e a majoro em 2/3 referente ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inc. I, do art. 157, do Código

Penal, alcançando a reprimenda de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, além de não ser suficiente nem eficaz à reprovação da conduta e nem à prevenção de outros delitos graves, sob pena de se estimular a criminalidade com o baixo castigo. Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a gravidade do crime, fixo o regime prisional fechado.

Nesse sentido vide jurisprudência: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada" (JUTACRIMSP 91/117).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado mediante desde a data dos fatos, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral, até porque o réu está preso há cinco meses, sem direito sequer à progressão de regime.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração .Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena "(STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano, por ausência de prejuízo patrimonial.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI, qualificado às fls. 11/12, como incurso no artigo 157, § 2º- A, inciso I, do Código Penal, e o faço para condenar à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em

regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, em 100 Ufesps, por ter constituído Advogada particular, sem pedido de concessão de justiça gratuita, menos ainda de comprovação e declaração de hipossuficiência.

O réu não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere em que está.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa.

Comuniquem-se as vítimas nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA